

1500276-79.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500276-79.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-79.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2024897/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 15911569 - DEL.SEC.BOTUCATU, 110/21/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2024897 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 110/21/200 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

NICOLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE e EVERSON RAFAEL APARECIDO CAMILO, qualificado nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29, “caput”, do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 18h26min, na Travessa Augusto Galvano, nº

460, Vila Antártica, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, vendiam e traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 16 (dezesseis) porções de maconha, individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 17,51g, bem como 08 (oito) porções de cocaína na forma de "crack", também embaladas individualmente, com peso líquido de 1,49g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação provisória (fls. 17/24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/107) juntados aos autos.

Conforme apurado, Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que possui equipamentos públicos municipais e é um conhecido ponto de venda de drogas na cidade de Botucatu, quando visualizaram quatro indivíduos naquela localidade.

Assim que o denunciado EVERSON percebeu a presença da viatura da Guarda Civil Municipal, gritou para seus companheiros: "Polícia, moiô, corre!" (fls. 03 e 04).

Em razão deste alerta, os quatro indivíduos saíram correndo em direção a um matagal localizado nas imediações, para tentarem fugir, mas os guardas civis municipais conseguiram persegui-los e alcançaram EVERSON e NICOLAS, abordando-os. Os outros dois rapazes lograram êxito na fuga.

Submetidos à revista pessoal, com NICOLAS foram encontradas, no bolso de sua bermuda, 16 porções de maconha e 08 pedras de "crack", além de um aparelho celular e R\$ 24,00 em cédulas diversas, dinheiro oriundo da traficância (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 17/24, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 105/107 e comprovante de depósito de fls. 104).

Indagado acerca dos fatos, EVERSON admitiu aos guardas civis municipais que auxiliava NICOLAS na venda das drogas, exercendo a função de "olheiro", certo que receberia sua contribuição em drogas, pois seria usuário.

O denunciado NICOLAS, por sua vez, informou aos guardas civis municipais que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas ao comércio ilícito, o numerário encontrado seria fruto da venda de drogas e EVERSON o auxiliava na prática do tráfico, certo que iria pagá-lo com a entrega de drogas.

NICOLAS foi preso em flagrante e EVERSON foi liberado.

Distribuído o flagrante, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante de NICOLAS em prisão preventiva (fls. 61/63).

Em 16/02/2021 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 109/111).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados no dia 17/02/2021 (fls. 115/120).

Foi proferida decisão fixando medidas cautelares ao corréu EVERSON (fls. 121/122).

O réu NICOLAS foi notificado em 08/04/2021 (fls. 160) e apresentou defesa prévia (fls. 187/188).

O réu EVERSON foi notificado em 14/10/2021 (fls. 216) e apresentou defesa prévia (fls. 242/247).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela

acusação e pela defesa e os réus foram interrogados (fls. 338).

O ministério Público apresentou memoriais orais pugnando pela procedência da ação, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 338).

Em alegações finais escritas, a defesa do acusado EVERSON, requereu a absolvição do réu por falta de provas (fls. 339/344).

A defesa do corréu NICOLAS apresentou alegações finais escritas requerendo a absolvição do acusado por falta de provas ou, subsidiariamente pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado (fls. 354/362).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Primeiramente, cumpre mencionar que, embora não conste dos autos a citação pessoal dos acusados, os mesmos participaram de todos os atos processuais, de modo que reconheço a citação tácita e não verifico nada a suprir ou declarar nulo.

Na questão de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls.01/02; o boletim de ocorrência (fls. 11/13); o auto de exibição e apreensão (fls.14/15); o laudo de constatação (fls.17/24); o laudo de exame químico toxicológico (fls.105/107); o relatório (fls.109/111); os depoimentos das testemunhas, e a versão dos acusados.

Interrogado em juízo o réu EVERSON relatou que no dia estava saindo da linha do trem, momento em que a viatura já jogou o depoente para dentro sem ao menos abordá-lo. Informou que não conhece as pessoas que correram. Relatou que Nicolas havia lhe perguntado onde conseguiria comprar maconha informando-lhe que próximo ao pé de manga havia um indivíduo vendendo entorpecente. Afirmou que Nicolas iria comprar 20 (vinte) reais em maconha e lhe daria 4 (quatro) reais pela informação, por ele ser morador de rua e usuário de drogas (essência do depoimento fls. 338).

Interrogado em juízo o réu NICOLAS, relatou que estava no local para adquirir entorpecentes. Afirmou que quando estava chegando no local avistou EVERSON que lhe informou que poderia adquirir entorpecentes no final da linha. Relatou que no local haviam três indivíduos vendendo drogas e no momento em que fora efetuar a compra a viatura chegou, sendo que os policiais começaram a gritar e deram um tiro de modo que correu para o mato. Em seguida foi abordado, todavia não estava na posse de nada ilícito, apenas R\$ 24,00. Informou que possui passagem pela Vara da Infância e Juventude e está respondendo um processo em liberdade. Relatou que estava trabalhando meio período com sua tia fazendo funilaria (essência do depoimento fls. 338).

A testemunha Carlos Alexandre Lauriano, GCM, relatou que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando avistaram Everson, e este avisou os demais indivíduos sobre a presença da viatura, de modo que todos empreenderam fuga. Informou que seu companheiro de farda deteve Everson, e mais a frente, o depoente deteve o Nicolas. Em revista pessoal foi localizado com o Nicolas 16 porções de maconha e 8 porções de crack, já com Everson, nada foi encontrado. Everson contou

para a equipe que auxiliava Nicolas nas vendas das drogas, que é usuário e que recebia, pelo auxílio nas vendas, entorpecentes (essência do depoimento fls. 338).

A testemunha Victor Zambonato Bariquelli, GCM, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram um grupo de pessoas e ouviram uma dessas pessoas gritando para os demais informando a presença da polícia. Na abordagem identificaram que foi Everson quem gritou, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse. Afirmou que com Nicolas foi encontrado uma quantia de entorpecente e dinheiro. Indagado, Nicolas afirmou que Everson era o olheiro enquanto ele vendia os entorpecentes. Relatou que Everson lhes contou que por ser usuário e morador de rua ajudava Nicolas em troca de entorpecentes (essência do depoimento fls.338).

Como se vê, os fatos imputados na inicial restaram satisfatoriamente demonstrados.

Não obstante a negativa dos acusados, afirmando serem meros usuários de drogas a versão por ele apresentada não encontra respaldo nas provas colhidas.

As narrativas apresentadas pelos Guardas Municipais foram uníssonas, no sentido de que os réus, após serem avisados por Everson da presença da viatura, empreenderam fuga, sendo, todavia, apreendidos. Relataram que em busca pessoal lograram localizar no bolso do shorts de Nicolas entorpecentes e dinheiro sendo confidenciado pelo mesmo que estaria realizando o tráfico no local. Já com Everson nada de ilícito foi localizado, todavia, tanto Nicolas como Everson afirmaram que este fazia o papel de "olheiro" em troca de entorpecentes, ficando demonstrado o conluio entre os acusados.

Ora, apesar dos acusados terem negado o tráfico de drogas, trazendo em seus interrogatórios judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os Guardas Municipais prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LIVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos GCM's são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelos réus; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelos acusados.

Outrossim, o laudo de fls. 105/107 resultou positivo para maconha e cocaína em forma de “crack”

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato dos réus, venderem e trazerem consigo, drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, os acusados vendiam e traziam consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, c.c. o artigo 29, “caput”, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas.

DO RÉU NICOLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE:

O acusado é primário (fls. 138/142). Contudo, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da quantidade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, com peso líquido de 17,51g, e 08 porções de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 1,49g), quantidade essa suficiente para razoável disseminação, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diminuo a pena em seu patamar mínimo tendo em vista a atenuante da menoridade

relativa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade, diversidade e potencialidade do entorpecente, bem como as passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 40), demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o crime e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos

depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

E ainda:

"TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras seguras dos policiais que efetuarão as diligências. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO. Impossibilidade. A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização. PENA. DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 11.343/06. Impossibilidade. Prova toda no sentido de que o réu se dedica a atividade criminosa desde a sua adolescência. RECURSO DESPROVIDO (Apelação criminal nº 990.09.031867-8, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Machado de Andrade, v.u., 18.06.2009).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

DO RÉU EVERSON RAFAEL APARECIDO CAMILO:

O acusado é primário (fls. 143/144). Contudo, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da quantidade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, com peso líquido de 17,51g, e 08 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 1,49g), quantidade essa suficiente para razoável disseminação, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato

decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento,

matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR NICOLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias no valor mínimo legal, e EVERSON RAFAEL APARECIDO CAMILO, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, ambos por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 c.c o artigo 29, "caput", do Código Penal.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 14/15), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu EVERSON RAFAEL APARECIDO CAMILO, tendo em vista que respondeu ao processo em liberdade, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

O réu NICOLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal,

Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I. C.

Botucatu, 13 de julho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA